

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 117/2534 อัยการ กรมอัยการ โจทก์
นาย สืบ ศักดิ์หรือลืม โรจนบุรานนท์ จำเลย
ป.อ. มาตรา 277, มาตรา 285, มาตรา 279
ป.วิ.อ. มาตรา 192

จำเลยเพียงแต่ใช้อวัยวะเพศของจำเลยถูกละเมิดสัมผัสที่ด้านนอกของอวัยวะเพศของผู้เสียหายซึ่งเป็นบุตรสาวของจำเลยจนสำเร็จความใคร่โดยไม่มีเจตนาสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศผู้เสียหายแต่อย่างใดจึงไม่มีความผิดฐานพยายามกระทำชำเรา แต่การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก และเป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดาน จึงมีโทษหนักขึ้นตามมาตรา 285 โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 และ 285 โดยไม่ได้ขอให้ลงโทษตามมาตรา 279 แต่ความผิดตามที่โจทก์ฟ้องนั้นรวมการกระทำผิดฐานกระทำอนาจารตามมาตรา 279 อยู่ด้วย ศาลจึงมีอำนาจลงโทษจำเลยตามความผิดที่พิจารณาได้ความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 285 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง, 285, 80 ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกจำเลย 6 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์มีเด็กหญิงจิตราภรณ์หรือกลอย โรจนบุรานนท์ ผู้เสียหายมาเบิกความเป็นพยานยืนยันการกระทำของจำเลยว่า วันเกิดเหตุเวลา ประมาณ 6 นาฬิกาผู้เสียหายแต่งตัวนักเรียนกำลังจะออกจากบ้านไปโรงเรียน จำเลย ซึ่งเป็นบิดาของผู้เสียหายห้ามไม่ให้ผู้เสียหายไปโรงเรียนในขณะนั้น แต่สั่งให้ผู้เสียหายถอดรองเท้าแล้วขึ้นไปชั้นบน ผู้เสียหายกลัวจึงปฏิบัติตาม เมื่อผู้เสียหายขึ้นไปชั้นบนแล้วจำเลยเดินตามขึ้นไป จำเลยปิดประตูและบอกให้ผู้เสียหายเปิดกระโปรง แล้วนอนลงผู้เสียหายทำตาม จำเลยถอดกางเกงชั้นในของผู้เสียหายออกและสั่งให้ผู้เสียหายถ่างขา หลังจากนั้นจำเลยนอนทับร่างของผู้เสียหายโดยถอดผ้าขาวม้าออก จำเลยกอดปล้ำผู้เสียหายและใช้อวัยวะเพศใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย กอดปล้ำอยู่นานประมาณ 15 นาที ก็มีน้ำขาว ๆ ออกมาจากอวัยวะเพศของจำเลย เห็นว่า ผู้เสียหายเป็นบุตรสาวแท้ ๆ ของจำเลย ไม่มีเหตุปรักปรำจำเลยซึ่งเป็นบิดาบังเกิดเกล้าของตนก่อนเกิดเหตุมีจำเลยกับผู้เสียหายและเด็กชายคนอง โรจนบุรานนท์ บุตรชายของจำเลยอยู่ในบ้านเกิดเหตุเท่านั้นเด็กชายคนองก็ได้เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ก่อนเกิดเหตุเล็กน้อยจำเลยพูดไล่ให้เด็กชายคนองไปตลาดและห้ามไม่ให้ผู้เสียหายไปโรงเรียนในขณะนั้น ฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุคงมีจำเลยกับผู้เสียหายเท่านั้นที่อยู่ในบ้านด้วยกันเพียงสองคน พฤติการณ์ของจำเลยเป็นการสร้างโอกาสที่จำเลย จะกระทำต่อผู้เสียหายได้โดยสะดวกเมื่อร้อยตำรวจเอกครรชิต รัตนชูวงศ์ พนักงานสอบสวนสถานตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ส่งตัวผู้เสียหายไปให้แพทย์ตรวจร่างกาย แพทย์หญิงนันทนา อังสุมาลิน ได้ตรวจพบคราบอสุจิและตัวอสุจิที่กางเกงชั้นในของผู้เสียหายตัวที่สวมใส่นำมาตรวจตามผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผลของแพทย์ เอกสารหมาย จ.9 เป็นการเชื่อมกับคำเบิกความของผู้เสียหายว่าจำเลยได้กอดปล้ำผู้เสียหายอยู่ประมาณ 15 นาที ก็มีน้ำขาว ๆ ออกมาจากอวัยวะเพศของจำเลยถูก

อวัยวะเพศของผู้เสียหาย ผู้เสียหายได้ใส่กางเกงชั้นในแล้วลงไปล้างน้ำปรากฏว่า
กางเกงชั้นในเปื้อนน้ำขาว ๆ ด้วย จึงเชื่อได้ว่าน้ำขาว ๆ ตามคำเบิกความของผู้
เสียหายคือน้ำอสุจิที่แพทย์หญิงนั้นพบเห็นนั้นเอง คำเบิกความของผู้เสียหายจึง
มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ รับฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำต่อผู้เสียหายตามคำเบิกความของผู้
เสียหายจริง หากใช่เป็นการปรักปรำใส่ร้ายจำเลยตามที่จำเลยฎีกาไม่ คดีมีปัญหาที่จะ
ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยต่อไปว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐาน
พยายามกระทำชำเราผู้เสียหายหรือไม่ เห็นว่า ผู้เสียหายเบิกความตอบโจทก์ว่า
จำเลยเอาอวัยวะเพศของจำเลยใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายได้
เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า จำเลยกอดปล้ำผู้เสียหายอยู่นานประมาณ 15
นาที อวัยวะเพศของจำเลยอยู่บริเวณหน้าอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ยังไม่ได้เข้าไป
ในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย คำเบิกความของผู้เสียหายจึงไม่แน่นอน การที่ผู้เสียหาย
เบิกความตอบโจทก์ว่าอวัยวะเพศของจำเลยได้เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย จึง
น่าจะเกิดจากความเข้าใจของผู้เสียหายซึ่งยังเป็นเด็กและอยู่ในภาวะตกใจกลัว อาจ
จะไม่ถูกต้องต่อความเป็นจริงได้ศาลฎีกาเห็นว่า ถ้าจำเลยได้ใส่อวัยวะเพศของจำเลย
เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ผู้เสียหายอายุเพียง 12 ปีเศษแพทย์หญิงนั้นพบ
น่าจะตรวจพบร่องรอยการร่วมเพศหรือน่าจะตรวจพบเชื้ออสุจิในปากช่องคลอดของผู้
เสียหาย หรือถ้าจำเลยพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย จำเลยก็ต้องใช้กำลัง
ดันอวัยวะเพศให้เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายในขณะที่ผู้เสียหายไม่ยินยอมผล
จากการกระทำดังกล่าวน่าจะตรวจพบรอยชำที่อวัยวะเพศของผู้เสียหายแต่ปรากฏผล
การตรวจของแพทย์หญิงนั้นพบเห็นตามเอกสารหมาย จ.9 ว่าไม่พบบาดแผลตาม
ร่างกาย ไม่พบบาดแผลฉีกขาดของอวัยวะสืบพันธุ์ตรวจน้ำในช่องคลอดไม่พบอสุจิ
และตัวอสุจิ และมีความเห็นว่าจะไม่พบหลักฐานยืนยันว่ามีการร่วมประเวณี แพทย์
หญิงนั้นทนายก็ได้มาเบิกความยืนยันตามความเห็นในเอกสารดังกล่าว พยานหลักฐาน
ที่โจทก์นำสืบมาจึงรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้กระทำชำเราหรือพยายามกระทำชำเราผู้

เสียหาย ตามพฤติการณ์ของจำเลยน่าเชื่อว่าจำเลยเพียงแต่ใช้อวัยวะเพศของจำเลย
ถูกละเมิดสัมผัสอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ด้านนอกจนสำเร็จความใคร่ โดยไม่มีเจตนา
สอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายแต่อย่างใด จำเลยจึงไม่มีความผิดฐาน
พยายามกระทำชำเราผู้เสียหาย ฎีกาส່วนนี้ของจำเลยฟังขึ้น แต่การกระทำของ
จำเลยเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรกและเป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดานมีโทษหนัก
ขึ้นตามมาตรา 285 แม้โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
277 และ 285 โดยไม่ได้ขอให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 279 ด้วย แต่ความผิดตามที่
โจทก์ฟ้องนั้นรวมการกระทำผิดฐานกระทำอนาจารตามมาตรา 279 ด้วย ศาลมี
อำนาจลงโทษจำเลยตามความผิดที่พิจารณาได้ความได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย จึงเห็นควรลงโทษจำเลยตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคแรก และ 285 ตามข้อเท็จจริงที่ได้ความในทาง
พิจารณา"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279
วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 285 ลงโทษจำคุกจำเลย 4 ปี

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น